

1501981-62.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... os policiais. Tem condenações por tráfico (foi confesso) e também pelo art. 157.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que o local dos fatos, onde existe uma praça pública com playground infantil e quadra esportiva, é conhecido ponto de tráfico. Relataram que estacionaram à distância, com vista para o ponto onde costuma ficar o responsável pela venda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501981-62.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501981-62.2022.8.26.0537 Controle nº 1497/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONI CARVALHO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

LEONI CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 19:00 horas, na Av. Marginal Z, altura do n.º 357, Bairro Conceição, próximo a uma quadra esportiva e recreativa, adquiriu, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 63/66).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 119/120), sendo recebida a denúncia em 21.11.22 (fls. 126). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos

especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, reincidência e por ter sido praticado o crime nas proximidades de quadra, afastada a redução do art. 33, § 4.º e fixação de regime fechado.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, a compensação da reincidência com a confissão extrajudicial, a aplicação do art. 387, § 2.º, do CPP e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 04), o réu confessou a prática do crime. Disse que trabalhava esporadicamente como conferente na empresa Tec Suporte, há aproximadamente 1 um, recebendo em média R\$ 1.200,00. Afirmou que era seu quarto dia no tráfico e que recebia 10% do valor auferido com a venda das drogas. Falou que costumava ficar na "biqueira" por 24 horas, que chegava ao local por volta das 08:00 horas e permanecia vendendo drogas até as 08:00 da manhã do dia seguinte. Narrou que todos os dias um homem desconhecido lhe entregava uma bolsa com as drogas, deixava o local e depois retornava no decorrer do dia, em horários incertos, para recolher o dinheiro arrecadado com a venda das drogas. Informou não saber onde tal homem poderia ser localizado. Relatou que estava na "biqueira" quando os policiais chegaram em um veículo, o abordaram e localizaram drogas no bolso da blusa dele. Indicou aos policiais o local aonde havia escondido a bolsa com o restante das drogas.

Em juízo, narrou que foi até o local para comprar drogas (2 maconha, 2 cocaína e 3 de "crack") para uso. Não havia jovens no local pelo horário, sentou na praça, estava fumando quando apareceu uma van, saíram policiais e o abordaram. O traficante foi embora e quem estava na quadra também se afastou. Narrou que estava de terno e ia para a faculdade. Os policiais foram até o mato e voltaram com a bolsa, mas não sabe onde acharam. Falou que foi coagido a assinar na delegacia, pois ficou com medo de ser agredido. Não falou com delegado, nem escrivão. Faz faculdade de Direito na Estácio de Santo André. Trabalhava como conferente de estoque para a empresa Tec Suporte. Não conhecia os policiais. Tem condenações por tráfico (foi confesso) e também pelo art. 157.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que o local dos fatos, onde existe uma praça pública com playground infantil e quadra esportiva, é conhecido ponto de tráfico. Relataram que estacionaram à distância, com vista para o ponto onde costuma ficar o responsável pela venda das drogas ("vapor"), quando observaram que o réu em atitude suspeita, posto que mexia no mato existente na praça e depois retornava para a calçada. Então, resolveram abordá-lo. Narraram que em poder do réu localizaram 02 invólucros de maconha, 02 invólucros de cocaína e 03 pedras de "crack". Afirmaram que o réu confessou e disse que era o quarto dia de trabalho dele no local. Informaram que o réu indicou o local em que guardava as demais drogas, as quais foram apreendidas (uma bolsa escondida em uma moita, aos fundos da praça).

William (policial), em juízo, narrou que o local é conhecido como ponto de tráfico. O réu estava sozinho no local que fica o "vapor", viram que ia até o mato, atrás da praça, e voltava, então o abordaram. Disse que o réu confessou, que em seu poder havia 2 maconhas, 2 cocaínas e 3 de "crack" e no local que ele ia no mato havia uma bolsa mais porções de drogas. Informou que ao lado da praça há quadra aberta para as crianças. Não viram usuários, nem havia dinheiro.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Adriano. Não conhecia o réu anteriormente. Há um playground e uma quadra atrás da praça.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por

desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). A quantidade (fls. 37 - 11 tubos de lança-perfume, 06 pedras de "crack", 52 invólucros de cocaína e 46 invólucros de maconha) e variedade de drogas apreendidas (lança-perfume, "crack", cocaína e maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, as confissões informal e extrajudicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

A negativa judicial do réu está isolada, posto que alegou que é usuário, mas nada provou como lhe incumbia nos termos do art 156 do CPP e sua versão foi desmentida pelos policiais no sentido de que o viram em atos típicos de tráfico, a confissão informal e extrajudicial, que foram apreendidas drogas em seu poder, apontou onde estavam o restante, local para o qual o viram indo e depois voltando. A falta de apreensão de dinheiro também não o inocenta, posto que informou que passa o "recolhe".

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (11 tubos de lança-perfume, 06 pedras de "crack", 52 invólucros de cocaína e 46 invólucros de maconha), demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 42/44) e laudo definitivo (fls. 84/86; fls. 115/117- droga líquida).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos, possui antecedentes (fls. 49 - proc. 5432-61.2007 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 17.03.15 - fls. 58) é reincidente (fls. 49/50 - proc. 14137-14.2008 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 14.05.19; fls. 50 - proc. 37597-06.2003 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 14.05.19 - fls. 58) e possui um processo em andamento (fls. 142), que não pode ser considerado para quaisquer fins, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, especialmente que possui antecedentes, em razão da quantidade média de drogas (11 tubos de lança-perfume, 06 pedras de "crack", 52 invólucros de cocaína e 46 invólucros de maconha), já que pequena quantidade em Diadema é inferior a 100 porções, em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência e a confissões extrajudicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.ª Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:
Processo
AgRg no Resp 1406723 / DF
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2013/0328868-9
Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

Aumento a pena de 1/6, nos termos do art. 40, inc. III da Lei n.º 11.343/06, porquanto restou demonstrado que a traficância ocorria muito próximo à quadra esportiva e recreativa, conforme depoimentos dos policiais e "croqui" do local dos fatos (fls. 162/163).

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois possui antecedentes (fls. 49 – proc. 5432-61.2007 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 17.03.15 – fls. 58) e é reincidente específico (fls. 49/50 – proc. 14137-14.2008 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 14.05.19) e por roubo (fls. 50 – proc. 37597-06.2003 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 14.05.19 – fls. 58), o que denota personalidade voltada para crimes, que são seu meio de vida, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat

generalis" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto. Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante dos antecedentes por posse de drogas e reincidência, inclusive específica (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO LEONI CARVALHO DOS SANTOS à pena de 7 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES e 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 793 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei 8072/90, bem como o requerimento do M.P de não recorrer em liberdade e por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), inclusive conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, recomende-se na prisão em que se encontra. Sem custas (Lei n.º 11.608/03 por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto à bolsa tipo estojo da marca aparente "Nintendo DS", apreendida (fls. 37) e já periciada (fls. 113/114), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada. Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 68) e efetue-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA